

1528024-27.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cynthia Torres Cristofaro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... de todas as elementares do delito de tráfico, que se configurou consumado, clara a tipicidade, não havendo dúvidas quanto à autoria, caracterizada por comparsaria, correta a classificação dada à conduta. Não concorre o necessário ao reconhecimento também do crime de associação para o tráfico.

O réu Márcio, na fase policial, disse que realmente estava no local dos fatos para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1528024-27.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1528024-27.2021.8.26.0228 - 2021/001529

Autora:

Justiça Pública

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Réu:

MARCIO ROGERIO MORAES CAMARA DA SILVA e ADEMIR DAGUIA DE CASTRO

Juíza de Direito: Dra. Cynthia Torres Cristófar

Vistos.

MARCIO ROGERIO MORAES CAMARA DA SILVA e ADEMIR DAGUIA DE CASTRO, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, em combinação com o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque, no dia 17 de novembro de 2021, em hora incerta, na Rua Dolce-Alisso, defronte ao número 75, Vila Curuça, nesta cidade e Comarca, durante a vigência de estado de calamidade pública decretado em decorrência da pandemia do covid-19, ter-se-iam associado para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como porque teriam, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, previamente ajustados e em identidade de desígnios entre si, possuído, guardado e tido em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 67,5 gramas de maconha, 18,8 gramas de cocaína e 4,3 gramas de crack, substâncias determinantes de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os réus foram presos em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 110/114).

Os acusados foram regularmente citados e notificados (fls. 157 e 159), e apresentaram defesa preliminar por meio da Defensoria Pública (fls. 162/163), recebida a denúncia (fls. 165) e renovada a citação.

Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos de duas testemunhas, tendo sido os réus interrogados.

Manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos termos da denúncia; pleiteou a defesa a absolvição, por falta de provas, pretendendo subsidiariamente a desclassificação ao delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006 ou a fixação de penas no mínimo, atenuadas por menoridade relativa / por confissão / compensada reincidência por confissão, com máxima redução, em regime brando tomada detração, com substituição, sendo facultado recurso em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória comporta parcial acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico, que se configurou consumado, clara a tipicidade, não havendo dúvidas quanto à autoria, caracterizada por comparsaria, correta a classificação dada à conduta. Não concorre o necessário ao reconhecimento também do crime de associação para o tráfico.

O réu Márcio, na fase policial, disse que realmente estava no local dos fatos para vender drogas, as quais deixava escondidas em meio a sacos de lixo (fls. 14). Ouvido em Juízo, é usuário de cocaína, sua mãe, que tem uma loja, lhe deu 100 reais, então foi ao local para comprar cocaína, comprou dois pinos a 10 reais cada um, ficou ainda com 50 reais, depois ficou sentado pelo local, segundo disse porque queria comprar mais; os policiais civis apareceram, o menino de quem comprou correu para o fundo da favela e não foi abordado; foi perguntado sobre onde estavam as drogas, não sabia informar, alguém falou ao policial pelo telefone e ele então apreendeu as drogas; Ademir, que conhecia de vista, estava no local catando reciclagem e também foi abordado; não conhecia os policiais anteriormente, não tendo sabido informar motivo para suas afirmações; tem condenação anterior por tráfico.

O réu Ademir, na fase policial, disse que estava desempregado, sem fazer nada, e por consequência ajudando o comparsa (fls.16). Ouvido em Juízo, negou a prática do delito; encostou no local para comprar drogas, o traficante não estava, sentou perto de alguns rapazes, entre eles Márcio, depois viu que estes se levantaram e foram em direção a um sujeito, então foi também; foi abordado por policiais e Márcio também, os traficantes viram e se afastaram; tinha consigo somente 26 reais, dentro da carteira; trabalhava catando materiais recicláveis conseguindo ganhar cerca de 100 reais por dia, o dinheiro que tinha consigo era proveniente disso; não conhecia os policiais anteriormente, não tendo sabido informar razão para suas afirmações; teve condenações anteriores por roubo, receptação e porte de arma. As negativas apresentadas pelos acusados em Juízo, carentes de verossimilhança, vêm isoladas nos autos, confrontadas pelo mais da prova colhida, a que conformes as confissões dadas na fase policial e mal desmentidas em Juízo, demonstrada à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

As circunstâncias da prisão e da apreensão foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então os acusados, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

Os policiais civis Eduardo e José Roberto relataram em Juízo que o local, numa comunidade, é conhecido como ponto de tráfico, com várias solicitações por disqued- denúncia e prisões; foram ao local e fizeram campana por cerca de 10 minutos de viatura descaracterizada e por mais uns 5 minutos a pé, a uns 25 metros de distância, e observaram que duas pessoas, separadamente, foram ao réu Márcio, deram-lhe dinheiro, ele então deu um toque em Ademir, que foi a um monte de lixo a uns 10 ou 15 metros, pegou droga, trouxe e entregou para Márcio, que então entregou ao comprador; não puderam abordar os compradores; abordaram os réus, com Márcio havia dois pinos de cocaína, um celular e cerca de 70 reais em dinheiro trocado; com Ademir havia 25 reais em dinheiro trocado; foram ao montinho de lixo, procuraram e encontraram em um saco dentro do lixo cerca de 50 porções de cocaína, com as mesmas embalagens das que estavam com Márcio, cerca de 50 porções de maconha

e cerca de 17 porções de crack; Márcio confessou prontamente que estava traficando, Ademir disse que não traficava, mas quando informado que tinha sido visto indo buscar a droga, disse que estava só ajudando Márcio e que não fazia parte do tráfico; não houve testemunha que pudessem conduzir; Ademir estava mal vestido, mas não souberam esclarecer se ele era usuário de drogas.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, inclusive no tocante à confissão informal a eles prestada por ocasião da abordagem, convindo notar que os réus não eram conhecidos anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Bem assentado, assim, que os réus foram surpreendidos quando postados em ponto estabelecido de tráfico, tendo sido observados em plena atividade no comércio ilícito, Márcio recebendo o dinheiro dos usuários enquanto Ademir buscava a pouca distância as drogas para que o comparsa as entregasse aos compradores, descoberto pela observação realizada o esconderijo das drogas.

O conjunto probatório é seguro e convincente, dado que é pelos relatos coincidentes das testemunhas, a que conformes inclusive as confissões dadas por ambos os acusados na fase policial, mal desmentidas em Juízo, de tal sorte que materialidade e autoria do delito de tráfico encontram-se perfeitamente comprovadas.

As drogas vêm descritas no auto de apreensão de fls. 54, estando a materialidade do delito demonstrada pelo auto de constatação de fls. 55/58 e pelo laudo químico toxicológico de fls. 151/153, em que apontada a presença dos princípios ativos característicos nas substâncias apreendidas.

A quantidade (117 porções), a variedade (maconha, cocaína e crack), o modo de disposição das drogas e as circunstâncias em que apreendidas, quando postados e em plena atividade do comércio ilícito os réus em ponto estabelecido de tráfico, não se mostram compatíveis com destinação outra que não o comércio ilícito, de que claramente proveniente o dinheiro apreendido.

Embora bem estabelecida a comparsaria, notada a atuação concatenada entre os dois acusados na guarda e venda das drogas, a prova dos autos não permite que se reconheça que, para além disso, viessem associados de modo algo perene para a prática do ilícito: não consta tenham sido pilhados em outra ocasião na prática conjunta de qualquer outro crime, nada dizendo que mantenham algum laço mais duradouro.

A condenação dos acusados pelo tráfico é de rigor. Passo à dosagem das penas que lhes serão impostas.

Aos delitos descritos pelo caput do artigo 33 da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, as quais, consideradas exclusivamente para fixação da base, não se mostram de todo desfavoráveis aos acusados, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há atenuantes genéricas incidentes, sendo que não teriam o condão de conduzir a reprimenda a quem do mínimo legal, em observância ao princípio da legalidade (Súmula STJ 231).

Não obstante a reincidência dos réus, uma vez que tal circunstância atuará adiante para obstar a diminuição da pena na forma do parágrafo 4º ao artigo 33, consistindo circunstância elementar do crime, não se presta a caracterizar a agravante genérica prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal, desde que assim não fosse ocorreria bis in idem.

Não atua, ademais, a agravante do artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, apontada na denúncia, reformulado, nesse ponto, o entendimento Juízo.

Com efeito, muito embora o crime realmente tenha sido praticado quando em vigor situação de calamidade assim reconhecida pelo poder público, decorrente da pandemia da doença provocada pelo corona vírus, não se observa que essa circunstância tenha sido algo relevante na prática do delito ou mesmo que da conduta tenha resultado algum efeito sobre a situação calamitosa.

Tratando-se, no caso, de circunstância meramente accidental, que não propiciou

facilidade para a prática criminosa e nem tampouco foi impactada pela condutado réu, não justifica o agravamento da punição.

Nesse sentido:

Ação Penal - Tráfico de Drogas - Sentença condenatória - Apreensão de maconha - Insurgência do réu - Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 - Não cabimento - Circunstâncias da prisão e quantidade de entorpecentes apreendidos que afastam tal pretensão - Dicção do disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Dosimetria. Primeira fase - Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes e da quantidade de entorpecente apreendido (quase 1 kg de maconha), na fração de 1/6 (05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa). Segunda fase - Atenuante de confissão espontânea compensada com a agravante de reincidência - Ainda na segunda fase, incidiu a agravante de calamidade pública em razão do Covid19, na fração de 1/6 - Respeitado o entendimento do nobre julgador, a agravante contida no art. 61, II, alínea "j", CP, não tem aplicação no caso - Inexistência de relação de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública (Coronavírus) e a prática do tráfico de drogas - A exasperação da pena é devida quando o agente se aproveita de uma situação, para o cometimento do crime, o que não ocorre na espécie - Agravante afastada. Terceira fase - Redutor que não incidiu na espécie - Réu reincidente - Regime fechado que fica mantido - Recurso provido em parte para afastar a agravante de calamidade pública, redimensionando-se, assim, o quantum da reprimenda. Mantida, no mais, a r. sentença. (TJSP, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto, Apelação Criminal 1516263-33.2020.8.26.0228, deram parcial provimento, V.U., j. 25/3/2021).

No mesmo sentido: TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Andrade Sampaio, Apelação Criminal 1512777-40.2020.8.26.0228, j. 25/3/2021; TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Andrade Sampaio, Apelação Criminal 15'6422-73.2020.8.26.0228, j. 25/3/2021; e TJSP, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Francisco Bruno, Apelação Criminal 1517341-62.2020.8.26.0228, j. 25/3/2021.

Não incide a causa de diminuição prevista pelo parágrafo 4º ao artigo 33, dada a reincidência múltipla de Ademir e específica de Marcio, demonstrada pela FA de fls. 74 a 93 e pela certidão de antecedentes de fls. 99/104, e pela FA de fls. 94/96, pela certidão de fls. 105/106 e pelo extrato de fls. 171 e ss., de sorte que torno definitivas as penas fixadas.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime fechado, único que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, mesmo à vista do quantum fixado, considerada a gravidade objetiva da conduta em exame, que reclama reação severa, proporcional e seguramente eficaz, e atendida a reincidência.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câm. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Ausentes os requisitos legais, inviável a substituição da pena corporal. Apesar de suspensão vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pela Resolução 5/2.012 do Senado Federal, a natureza do delito não se coaduna com a benesse pretendida, cuja aplicação redundaria em comprometimento da finalidade da sanção penal, em especial no tocante à função de prevenção geral, não se afigurando a medida socialmente recomendável (art. 44, inciso III, e § 3º, CP).

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, os réus MARCIO ROGERIO MORAES CAMARA DA SILVA, qualificado a fls. 26, e ADEMIR DAGUIA DE CASTRO, qualificado a fls. 45, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, bem como para absolvê-los das demais imputações, com fundamento no disposto pelo artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar dos acusados no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena, é patente o risco de que soltos procurem obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhes facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Autorizo que se proceda à destruição das drogas apreendidas. Oficie-se desde logo para tanto.

Após o trânsito em julgado a) elaborem-se cálculos de multa e intimem-se os réus para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeçam-se e encaminhem-se cartas de guia / aditamento; c) proceda-se à transferência do dinheiro apreendido a fls. 54 e depositado a fls. 124/125 ao Funad, decretado seu perdimento em favor da União; d) não reclamada a restituição do aparelho celular apreendido a fls. 54 em até 90 dias seguintes ao trânsito em julgado por quem comprove documentalmente regular aquisição, oficie-se para leilão com recolhimento do valor apurado em conta judicial; e) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, intimadas as partes. Comunique-se.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2022.

VAI ESTE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, CONFORME É APONTADO EM SUA MARGEM SUPERIOR / DIREITA